Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

Autos n° 0834888-51.2020.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Rubens Bergonzi Bossay
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

SENTENÇA
I - RELATÓRIO

RUBENS BERGONZI BOSSAY, com qualificação nos autos, propôs **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA** em face de **UNIMED - CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, também com qualificação nos autos, formulando os seguintes pedidos:

> ***"a) condenar o plano de saúde Réu a reembolsar o Autor pelo dispêndio com a aquisição do remédio, no valor de R$ 32.300,00 (em 29/09/2020) e fornecer àquele a medicação prescrita pelo médico (Osimertinibe – Tagrisso – 80mg/dia, para uso contínuo), enquanto subsistir a necessidade;***
>
> ***b) condenar o plano de saúde Réu ao pagamento de reparação pelos danos morais causados, arbitrando-se indenização mínima – sem prejuízo de valor maior – de R$ 10.000 (dez mil reais), arcando aquele com os ônus da sucumbência".***

Como causa de pedir, sustenta que que é beneficiário do plano de saúde da parte requerida e foi diagnosticado com câncer de pulmão (carcinoma

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

de pulmão de células não pequenas (adenocarcinoma primário de pulmão metastático –EGFR mutado – mutação do éxon 21-L858R).

Aduz que, diante do diagnóstico, o médico optou seguir o tratamento quimioterápico oral com o uso do medicamento denominado "OSIMERTINIBE (TAGRISSO)", visto que tal medicação é a mais indicada para seu quadro clínico.

Afirmou que solicitou à parte requerida a autorização para a realização do tratamento nos termos solicitados pelo médico, no entanto, a requerida não autorizou o tratamento, sustentando que o medicamento não está elencado na lista de medicamentos para terapia antineoplásica oral das Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na saúde suplementar da Agência Nacioanal de Saúde.

Por tais motivos, foi obrigado a adquirir uma caixa do referido medicamento por R$ 32.300,00 (trinta e dois mil e trezentos reais), na data de 29/09/2020.

Na decisão de fls. 856/864 foi deferida a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida autorize o início do tratamento com o fornecimento do medicamento pleiteado – "Osimertinibe (tagrisso)", nos termos solicitados pelo médico da parte autora.

Contra tal decisão, a parte requerida interpôs agravo de instrumento, que teve provimento negado (fls. 1043/1059).

A parte requerida foi citada (fl. 872), sendo que compareceu aos autos e ofertou contestação (fls. 873/901), alegando, em síntese o seguinte: 1) impugnou o valor da causa; 2) tece considerações sobre o plano de saúde; 3) afirma que não é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, uma vez que o medicamento solicitado não está previsto no rol da ANS e não está previsto em contrato; 4) aduz que forneceu tratamento convencional à parte autora, nos termos do contrato; 5) afirma que não praticou nenhum ato ilícito; 6) sustenta que agiu no exercício regular do direito; 7) que

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

não estão presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, a ensejar danos morais; 8) pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora impugnou os termos da contestação na manifestação de fls. 1029/10/41.

Foi designada audiência de conciliação, a qual restou sem êxito (fl. 1083).

Houve a inversão do ônus da prova (fl. 1089).

As partes foram instadas a especificar as provas que pretendem produzir e postularam o seguinte: 1) a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 1096); 2) a parte requerida requereu a produção de depoimento pessoal da autora, prova testemunhal, documental e pericial (ainda que indireta) (fls. 1092/1095).

A parte autora juntou receitas e atestados médicos (fls. 1097/1101 e 1109/1114), sobre os quais a parte requerida se manifestou (fls. 1117/1118).

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.I – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Em que pese a parte requerida pugnar pela produção de prova oral e pericial (ainda que indireta), com a finalidade de comprovar a efetividade do tratamento requerido à parte autora, tais requerimentos devem ser indeferidos.

Com efeito, a prova oral e a prova perícia para provar a alegação de que o tratamento requerido pelo autor não era indicado à sua patologia são desnecessárias, uma vez que o pedido está amparado em prescrição de profissional que o acompanha.

Ademais, o pleito nos termos em que está formulado pela

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

requerida, aparentemente, busca firmar uma premissa de julgamento para o feito, o que é processualmente inadequado, posto que constituiria tentativa de obter um "parecer" para substituir a prescrição do médico que realiza o tratamento da autora.

Ressalta-se que, na atividade de julgar, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, ***"O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento"***, de modo que a análise de eventual obrigação de fazer deve ser realizada levando-se em consideração as resoluções atinentes ao caso e ao Código Civil.

Na espécie, incide o disposto no at. 355, I, do Código de Processo Civil, no qual assevera que "***O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas".***

Logo, **INDEFIRO** a produção de prova pericial e oral requeridas pelas partes e passo analisar a julgar antecipadamente a presente ação.

II.II - PRELIMINAR
II.II.I – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Na contestação, a parte requerida ofertou impugnação ao valor da causa, sustentando que o valor apontado na inicial - R$ 100.000,00 (cem mil reais) - mostra-se muito elevado, pugnando pela retificação do valor para um valor condizente ao caso em tela.

Sobre o valor a ser atribuído à causa, dispõe o art. 292 do Código de Processo Civil:

> ***"Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:***
>
> ***I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal".

Assim, nos termos do art. 292, V, do Código de Processo Civil, o valor da causa será, na ação indenizatória, o valor pretendido.

No caso em tela, a parte autora pleiteia a condenação da requerida na cobertura do medicamento ""OSIMERTINIBE (TAGRISSO)".

A própria autora afirma que uma caixa de tal medicamento custa entre R$ 30.000,00 (trinta mil) a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tendo a parte requerida concordou com tal afirmação (fl. 874).

Ademais, a parte autora refere que lhe foi prescrito o uso de uma dose de 80mg por dia, continuamente, conforme receitas de fl. 17 e 19.

Desta forma, estando nos estritos termos do art. 292, V, do Código de Processo Civil, o valor atribuído à causa pela parte autora encontra-se correto, não havendo se falar em sua modificação.

Diante do exposto, **INDEFIRO A PRELIMINAR** sustentada na contestação.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

II.III - MÉRITO

II.III.I – OBRIGAÇÃO DE FAZER

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, na qual a parte autora busca a condenação da requerida em proceder a assistência médica para a realização do tratamento com medicamento Osimertinibe (tagrisso), bem como a condenação no pagamento de indenização por danos materiais (reembolso dos valores gastos com uma caixa do referido medicamento), além de indenização por danos morais.

Inicialmente, importante destacar que a atividade de prestação de assistência médico-hospitalar está abrangida pelo Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, a teor do que disciplina do artigo 3º, § 2º, do CDC, corroborado pelo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 608, ***"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".***

Em semelhantes litígios deve ocorrer a facilitação da defesa do consumidor em juízo e pode até ser determinada a inversão do ônus da prova, tudo nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, e com base na legislação consumerista, deve-se repelir do contrato firmado entre as partes toda e qualquer cláusula que implique em contrariedade à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

Com isso, é possível afirmar que os direitos básicos do consumidor e as suas normas protetivas devem todas ser aplicadas no contrato em questão, principalmente o art. 6º, V, que estabelece a possibilidade da quebra da base objetiva do contrato, excetuando, portanto, o princípio do *pacta sun servanda.*

Além disso, ressalta-se que permanece a obrigação dos planos de saúde de cumprirem as obrigações legais e contratuais.

Os artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, dispõem:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé";

"Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente";

"Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio".

O art. 422 acima mencionado, consagra o princípio da boa-fé objetiva, consoante o qual as partes devem se comportar com probidade e boa-fé desde a formação do contrato e também durante toda a sua execução.

Nas lições de CARLOS ROBERTO GONÇALVES, por decorrência de tal princípio, o juiz ***"Deve este, ao julgar demanda na qual se discute a relação contratual, dar por pressuposta a boa-fé objetiva, que impõe a um contratante um padrão de conduta, de agir com retidão, ou seja, com probidade, honestidade e lealdade, no moldes do homem comum, atendidas as peculiaridades dos usos e costumes do lugar"([1])***.

A respeito do alcance de tal princípio, o E. STJ e E. TJ/MS decidiram o seguinte:

"(...) Todo contrato desempenha uma função social, deve ser interpretado conforme a boa-fé e também deve guardar desde a conclusão e durante a sua execução esse mesmo princípio, assim como o da probidade (arts. 113 e 422 do CC/02).(...)." ([2]).

"(...) Viola a boa-fé objetiva dos contratos adotar conduta divergente do pactuado e esperado pelo contratante, de modo que o comportamento contraditório e desleal, implica em exercício abusivo de direito ferindo o interesse social das relações jurídicas. (...)" ([3]).

---

[1] DIREITO CIVIL BRASILEIRO, ed. Saraiva, 2008, volume III, p.33.

[2] **STJ**; REsp 1363814/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 30/10/2017.

[3] **TJMS**. Apelação n. 0809609-05.2016.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 29/01/2019, p: 31/01/2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

Ademais, observa-se que, na existência de cláusulas ambíguas ou contraditórias em contratos de adesão, o contratante é beneficiado com a interpretação mais favorável, bem como que eventual limitação contratual deve ser considerada nula.

Nesse diapasão, a Lei nº 9.656/1998, que trata dos Planos Privados de Saúde, é expressa em estabelecer, no artigo 10, o plano de referência de assistência à saúde, com as coberturas médico ambulatorial e hospitalar, trazendo as coberturas mínimas de qualquer plano, ou seja, os itens que todo plano de saúde deve cobrir, tais sejam:

> ***"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:***
>
> ***I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;***
>
> ***II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;***
>
> ***III - inseminação artificial;***
>
> ***IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;***
>
> ***V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;***
>
> ***VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;***
>
> ***VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;***
>
> ***IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;***
>
> ***X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente".***

Da mesma forma, também tem como exigência mínima de tais contratos, a previsão de cobertura de *"cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente"*,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

conforme se observa do art. 12, I, "b", da referida Lei:

> ***"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:***
> ***I - quando incluir atendimento ambulatorial:***
> ***(...)***
> ***b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente (...)".***

Logo, constata-se que, via de regra, o tratamento médico adequado e que foi indicado pelo médico da autora, deve ser coberto pelo plano de saúde.

Nesse ponto aliás, a jurisprudência do E. STJ ***"reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas."*** (AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

No mesmo diapasão, certamente diante da quantidade de demandas sobre a matéria, o E. TJ/SP editou as súmulas 96 e 102, que assim dispõem:

> ***"Súmula 96 - Havendo expressa indicação médica de exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento".***
>
> ***"Súmula: 102 - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS".***

Também a jurisprudência do E. TJ/MS trilha no mesmo caminho, como se vê dos julgados a seguir transcritos, os quais foram colhidos entre muitos de igual teor:

> ***"E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA EM***

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

PRIMEIRO GRAU – LIMITAÇÃO DE COBERTURA RELATIVA A TRATAMENTO RPG – AUSÊNCIA DE COBERTURA DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – CLAUSULA ABUSIVA – RELAÇÃO CONTRATUAL – COBERTURA DE FISIOTERAPIA – NÃO CABE AO PLANO DECIDIR QUAL MÉTODO E SIM AO MÉDICO – TUTELA CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não cabe ao plano decidir qual tratamento deve ou não ser utilizado para recuperação da saúde de um paciente. 2. Uma vez disponibilizada a cobertura ela não pode dizer quais procedimentos, materiais ou técnicas serão utilizadas no tratamento da doença para a qual o contrato preveja cobertura" ([4]).

"E M E N T A – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SÍNDROME MIELODISPLÁSTICAS DO SUBTIPO ANEMIA REFRATÁRIA – DIREITO DO PACIENTE A RECEBER O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO QUE O ACOMPANHA – URGÊNCIA DA MEDIDA PARA TRATAMENTO E CONTROLE DA PATOLOGIA QUE PROGRIDE COM POSSIBILIDADE DE ÓBITO – REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – POSSIBILIDADE DE SER PROFERIDA DECISÃO MONOCRÁTICA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, VIII, DO CPC/2015 C/C 138, IV, DO RITJMS – AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA – RECURSO IMPROVIDO. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Diante da autorização de se proferir decisões monocráticas, concedida pela junção dos artigos 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 com o art. 138, IV, do RITJMS, não há que se falar em nulidade. Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum que negou provimento de plano ao recurso ante a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios" ([5]).

No presente caso, a parte autora sustenta que tem diagnóstico de câncer de pulmão e lhe foi indicado pelo médico que a assiste a realização do tratamento com o uso do medicamento denominado OSIMERTINIBE (TAGRISSO) 80mg, visto que tal medicação é a mais indicada para seu quadro clínico.

Afirma que requereu à parte requerida a realização do tratamento, mas seu pedido foi negado, sob a justificativa de que a solicitação não atende os critérios das Diretrizes de Utilização -DUT, ou seja, não está incluso no rol de coberturas mínimas exigidas pela ANS.

[4] **TJMS**; Agravo de Instrumento - Nº 1406439-42.2017.8.12.0000 - Dourados Relator : Exmo. Sr. Des. Amaury da Silva Kuklinski, julgado em 25/07/2018.
[5] **TJMS**; Agravo Interno - Nº 2000334-79.2018.8.12.0900/50000 - Bela Vista - Relator – Exmo. Sr. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, julgado em 25/07/2018.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

A requerida, por sua vez, sustenta que a realização do tratamento com o uso do medicamento denominado OSIMERTINIBE (TAGRISSO) 80mg não está contemplada com cobertura pelas Diretrizes de Utilização - DUT, bem como que não está previsto no rol de coberturas mínimas exigidas pela ANS.

Em que pese a manifestação da requerida e a negativa de fls. 841/842, tal tese não merece prosperar.

É cediço que, o contrato firmado pelas partes é de trato contínuo visando à prestação de serviços de assistência à saúde, de modo que, havendo previsão de cobertura para a doença que o paciente pode apresentar, como no presente caso, é justa a sua expectativa de cobertura para a busca do tratamento médico que lhe for recomendado.

Ressalta-se que a finalidade do contrato em questão, assim como a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, permite o reconhecimento de que a recusa pela requerida foi injusta.

No que se refere ao pedido de fornecimento do medicamento objeto dos autos, a matéria posta a decisão já foi objeto de decisão em outros feitos, nos quais se reconheceu o dever do plano de saúde fornecer tal medicamento, mesmo que não conste do rol de procedimentos da ANS, como se vê dos julgados a seguir transcritos, os quais referem-se especialmente sobre o medicamento indicado à parte autora:

> ***"APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Segurada diagnosticada com adenocarcinoma. Alegada negativa de cobertura do tratamento prescrito com o medicamento Osimertinibe 80mg. Sentença de procedência, a fim de condenar a ré a custear o tratamento de acordo com prescrição médica, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais. Insurgência. Não acolhimento. Rol da ANS que é exemplificativo. Havendo previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

Súmula nº 102 deste Tribunal. Negativa de custeio de tratamento comprovadamente essencial para garantir a saúde da paciente que, ademais, coloca em risco o objeto do contrato. Inteligência do art. 51, IV, do CDC. Precedentes desta Câmara. Dano moral. Injusta recusa de cobertura que caracteriza dano moral indenizável. Inexistência de dúvida razoável no contrato. Indenização fixada em R$ 10.000,00 que se revela razoável diante das peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (V. 33324)" ([6]).

"APELAÇÃO. Plano de Saúde. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais. Alegação de negativa do plano de saúde para cobertura de tratamento quimioterápico com o fornecimento do medicamento Osimertinibe prescrito a autora. Sentença de parcial procedência para condenar a ré na obrigação de autorizar e custear o tratamento descrito na inicial. Inconformismo da autora. Pugnando pela indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e a condenação da ré no pagamento da sucumbência de forma integral. Parcial cabimento. Recusa da ré considerada ilegal. Danos morais caracterizados. Valor fixado em 10.000,00. Recurso parcialmente provido" ([7]).

Dessa forma, a parte requerida não poderia negar o fornecimento do tratamento pretendido, indicado por médico responsável pelo acompanhamento da saúde da parte autora (fls. 17/19).

Ademais, são indiscutíveis os benefícios da realização de tal tratamento para estancar a evolução da doença, logo, não se visualiza qualquer justificativa plausível a negativa no fornecimento do referido medicamento.

No que tange a alegação de que o medicamento requerido não está previsto no rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, a mesma não merece prosperar, uma vez que a listagem feita pela agência reguladora não é taxativa.

Isto porque, cuida-se de uma relação mínima, de uma lista de consultas, exames e tratamentos que os planos de saúde contratados a partir de 02 de janeiro de 1999 são obrigados a fornecer.

O rol da ANS é meramente exemplificativo e, havendo

[6] **TJSP;** AC 1013086-51.2019.8.26.0003; Ac. 13729471; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Viviani Nicolau; Julg. 07/07/2020; DJESP 20/07/2020; Pág. 1931.

[7] **TJSP;** AC 1054518-50.2019.8.26.0100; Ac. 13724400; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto; Julg. 07/07/2020; DJESP 13/07/2020; Pág. 3347.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

expressa indicação médica, como ocorreu na espécie, é abusiva a negativa de cobertura de custeio do tratamento médico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou em caso semelhante:

> ***"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. A orientação desta Corte Superior é de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. 3. Na espécie, não há que se falar no afastamento da presunção de dano moral, porque o Tribunal de origem, soberano na análise de matéria fático-probatória, destacou que não houve dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, mas sim declaração de sua nulidade por restringir direitos e obrigações inerentes ao próprio contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial a fim de reconhecer o cabimento da indenização por dano moral. Incidência das Súmulas nºs 7 e 83 do STJ. 5. Inaplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo regimental não provido" ([8]).***

Portanto, comprovada a necessidade de realização do tratamento com o uso do medicamento denominado OSIMERTINIBE (TAGRISSO) 80mg e não havendo nos autos qualquer motivo para infirmar a veracidade do que foi atestado pelo médico da paciente, o pedido de obrigação de fazer deve ser julgado procedente, ratificando-se os termos da decisão que concedeu a tutela de urgência à parte

[8] **STJ** - AgRg no REsp 1546908 / RS, Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 03/05/2016.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

autora.

II.III.II – DANOS MORAIS

Para que exista o dever de indenizar, como é sabido, é necessário que estejam presentes os elementos da responsabilidade civil, tais sejam: ação ou omissão, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo.

Nesse sentido são as disposições dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil vigente, que, assim dispõem:

> ***"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".***
>
> ***"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".***

Logo, provada existência da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que cause prejuízo a outrem, o responsável pela violação fica obrigado a reparar o dano causado.

No que pertine à caracterização do dano moral, são pertinentes as lições sempre atuais de Yussef Said Cahali "***Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral***;" ([9]).

Com efeito, as provas produzidas evidenciaram a necessidade do medicamento solicitado pelo médico da parte autora, mas houve falha na prestação de serviço, na contramão da função social do contrato e do âmago da sua essência.

[9] Dano Moral, ed. RT., 2000, p. 20.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

A propósito, importante destacar o julgado do Tribunal de Justiça deste Estado, a seguir transcrito:

> ***"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR RECHAÇADA – TRANSPLANTE DE RIM – DIREITO AO REEMBOLSO DO TOTAL DAS DESPESAS – DANOS MORAIS DEVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA, RECURSO CONHECIDOS, RECURSO DO PLANO DE SAÚDE NÃO PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas da forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). No caso específico, não há como negar a cobertura do total das despesas com o procedimento (transplante de rim), uma vez que definidos os valores de reembolso mediante critérios inespecíficos cujas informações não foram devidamente repassadas ao consumidor. (...) Na hipótese, restaram configurados os pressupostos necessários à configuração dos danos de ordem moral, porquanto a injusta recusa de cobertura de plano de saúde aumentou o sofrimento do segurado, que inegavelmente ficou abalado emocionalmente diante da recusa de cobertura para que realizasse a cirurgia que necessitava transplante de rim - procedimento essencial para o restabelecimento de sua saúde (...)" ([10]).***

Ressalta-se que tal recusa indevida da cobertura do plano de saúde, ocorreu em um momento delicado na vida da parte autora, que se trata de pessoa idosa (nascida em 09/09/1943).

Logo, a negativa à realização do tratamento indicado para a autora causou manifesto sofrimento desnecessário, de modo que o pedido de indenização por danos morais deve ser procedente.

Nesse contexto resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora, razão pela qual fixo o valor da indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente adequado à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, considerando ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas.

Deve ser considerado que a parte requerida é uma empresa

[10] **TJMS.** Apelação n. 0800769-47.2015.8.12.0031, Caarapó, 3ª Câmara Cível, Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 12/12/2017, p: 18/12/2017.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

de serviços médicos de grande porte, com grande número de clientes, que tem condições de prevenir a ocorrência de semelhantes ilícitos com tecnologia e mão de obra especializada, mesmo assim acabou por violar o direito da parte autora.

O valor fixado deverá ser atualizado pela variação do IGPM-FGV, desde a data desta sentença, com fim de preservar-se ante a espiral inflacionária.

Observo que a atualização monetária não constitui um *plus* no débito, mas mera recomposição de valores ante à espiral inflacionária, sendo adequada a utilização do IGPM/FGV, posto que se trata de índice que reflete a efetiva variação do custo de vida.

Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, nos termos da jurisprudência do STJ (Recurso Especial nº 903258/RS), o termo inicial dos juros de mora em reparação por danos morais deve ser a partir da fixação do valor da indenização.

O percentual dos juros moratórios deve corresponder a 1% (um por cento) ao mês, visto que se aplica ao caso disposto no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional (Enunciado 20 do CEJ).

II.III.III – DANOS MATERIAIS

A parte autora requereu a condenação da parte requerida ao reembolso do valor pago por uma caixa do medicamento aqui buscado - denominado OSIMERTINIBE (TAGRISSO) 80mg, pois não tinha uma definição com relação ao pedido formulado junto à parte requerida.

Para tanto, apresentou cópia da nota fiscal da compra do mencionado medicamento, pelo valor de R$ 32.300,00 (trinta e dois mil e trezentos reais), emitida na data de 29/09/2020 (fl. 849).

O pedido veio acompanhado do relatório do médico, receitas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

e demais exames que permitem concluir que tal medicamento era de uso imprescindível à saúde da parte autora, entretanto, foi negado pela parte requerida, em prática manifestamente abusiva, conforme acima declarado.

Logo, a parte requerida deve proceder o reembolso dos valores que a autora despendeu, eis que está devidamente comprovado o prejuízo.

O valor deverá ser atualizado pela variação do IGPM-FGV, desde a data do desembolso.

Observo que a atualização monetária não constitui um *plus* no débito, mas mera recomposição de valores ante à espiral inflacionária, sendo adequada a utilização do IGPM/FGV, posto que se trata de índice que reflete a efetiva variação do custo de vida.

Em relação aos juros moratórios, tal verba é devida a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil, visto que a citação torna constitui em mora o devedor.

O percentual dos juros moratórios deve corresponder a 1% (um por cento) ao mês, visto que se aplica ao caso disposto no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional (Enunciado 20 do CEJ).

III - DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos da fundamentação supra e com respaldo nos arts. 422, 423 e 424, 186 e 927, todos do Código Civil, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS** formulados na petição inicial para o fim de:

1) condenar a requerida em fornecer o medicamento OSIMERTINIBE (TAGRISSO) 80mg à parte autora e, por consequência, ratifico os termos da decisão que concedeu a tutela de urgência de fls. 856/864, ressalvando sua abrangência até a data do óbito; e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

2) condenar a parte requerida no pagamento de indenização por dano moral à parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pela variação do IGPM-FGV desde a data desta sentença, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, também desde a data desta sentença.

3) condenar a parte requerida em proceder o reembolso do valor que a autora despendeu com uma caixa do citado medicamento - R$ 32.300,00 (trinta e dois mil e trezentos reais), que deverá ser atualizado pela variação do IGPM-FGV desde a data do desembolso (em 29/09/2020), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação

Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais, à vista do grau de zelo do profissional, o local de prestação de serviço (atendimento na Comarca), a natureza e a importância da causa (pouca complexidade) e os atos processuais praticados (feito não instruído), fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §2º, I a IV, do Código de Processo Civil).

Julgo resolvido o mérito da causa na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Campo Grande/MS, *data do sistema*.

Wilson Leite Corrêa
Juiz de Direito
Documento assinado digitalmente

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 22/03/2022 às 19:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834888-51.2020.8.12.0001 e código vUolvs6T.